

1502391-02.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... venda no atacado, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502391-02.2022.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502391-02.2022.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

MÁRCIO MORAES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 16 de setembro de 2022, por

volta das 3h30min, na Rodovia dos Bandeirantes, altura do km 56, Casa Branca, nas dependências do posto "Graal 556", neste município e Comarca de Jundiá, trazia consigo e transportava para a entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 80 tijolos de cocaína, pesando cerca de 81 kg.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, nas dependências do posto "Graal 56", o acusado recebeu de terceiro não identificado, o entorpecente acima aludido e armazenando-o dentro de malas, a fim de que pudessem ser transportado.

Em seguida, Márcio empreendeu fuga na condução do veículo HB20, placa CVI0G18.

Policiais civis, que realizavam diligências no local dos fatos, receberam informações que uma carreta realizaria o transporte de grande quantidade de drogas da região de Mato Grosso do Sul para a cidade de São Paulo, sendo que o transbordo seria feito no posto de combustíveis "Graal 56".

Assim, para apurar tais informações, os agentes da autoridade se dirigiram ao local em viaturas descaracterizadas e permaneceram em campanha, conseguindo observar a existência de dois estacionamentos, sendo um destinado a carretas e caminhões e outro a veículos de passeio.

Apuraram, ainda, que uma pessoa não identificada saiu do estacionamento de caminhões e se aproximou, a pé, do automóvel HB20, placa CVI0G18, que já se encontrava estacionado no local há várias horas, e, após conversar rapidamente com Márcio, tal pessoa entrou no veículo. Ato contínuo, ambos se deslocaram até o estacionamento privativo de caminhões.

Os policiais perderam de vista o veículo conduzido por Márcio por alguns instantes, mas conseguiram localizá-lo novamente no momento em que deixava o estacionamento de caminhões. Márcio estava sozinho, motivo pelo qual os agentes da autoridade resolveram acompanhá-lo. Cerca de um quilômetro depois, diante da movimentação suspeita no estacionamento, os policiais resolveram interceptar o réu, logrando apreender, no interior do automóvel, mais precisamente no porta-malas, os 80 tijolos de cocaína.

Questionado, o acusado admitiu que receberia a quantia de R\$ 20.000,00 para realizar o transporte da droga.

Assim, pela quantidade da substância entorpecente e circunstâncias da apreensão, foi preso em flagrante.

Notificado, o réu apresentou defesa prévia.

Analisada a defesa apresentada, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência, ouviram-se seis testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o Promotor de Justiça analisou a prova e pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Requereu, ainda, a fixação da pena-base acima do patamar legal, tendo em vista a expressiva quantidade da droga apreendida, observância dos maus antecedentes, reconhecimento da atenuante da confissão e imposição de regime inicial fechado. Requereu, outrossim, a expedição de ofício à autoridade policial, a fim de apurar eventual prática do delito de receptação ou adulteração de sinal de veículo automotor.

A defesa, em preliminar, arguiu a ilegalidade das provas obtidas por revista pessoal e veicular, tendo em vista a violação do previsto no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. No mérito, buscou a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas para a condenação. Em caso de entendimento diverso, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal e da atenuante da confissão; aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; imposição de regime inicial diverso do fechado; concessão de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica se necessário e o direito de recorrer solto.

RELATADO.

DECIDO.

O pedido de prisão domiciliar de fls. 175/179 está superado nesta fase processual com a sentença proferida nesta data.

A preliminar suscitada não merece prosperar.

Com efeito, não há falar em ilicitude das provas, Conforme se vê do conjunto probatório coligido aos autos, a conduta dos policiais não foi arbitrária ou motivada por suspeita infundada, mas sim porque os agentes da autoridade receberam informação de que haveria entrega de grande quantidade de entorpecentes no posto de combustíveis mencionado na denúncia.

Assim, os policiais se dirigiram para o local dos fatos e permaneceram em campanha, ocasião em que avistaram o réu, que manteve seu veículo estacionado por várias horas no estacionamento de forma suspeita, até encontrar com outro indivíduo e com ele rumar até o estacionamento exclusivo para caminhões. Tal conduta motivou a interceptação do automóvel por ele conduzido, ocasião em que restaram apreendidos os 81 quilos de cocaína.

Também não há violação aos artigos 5º, inciso IV, da Constituição Federal e 240, § 2º, do Código de Processo Penal, já que havia justa causa para realização não só da interceptação e da revista, mas também para a busca veicular, que é equiparada à busca pessoal, sendo desnecessária a prévia autorização judicial, vez que o atraso da diligência poderia comprometer seus resultados.

Nesse sentido, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "(...) 2. A disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 3. Neste caso, as instâncias antecedentes informaram que os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado pelo agravante e pelo corréu após eles terem dispensado uma sacola pela janela do carro, posteriormente recuperada pela guarnição e que continha duas barras de maconha, totalizando cerca de 1,8kg de entorpecente, além de duas porções menores, de 168,9g. Os militares interceptaram o veículo e, em seu interior encontraram cerca de R\$ 11 mil em dinheiro" (AgRg no HC nº 770.281/MG, 5ª Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/09/2022).

Além disso, diante da natureza permanente da conduta ilícita do acusado e das prévias informações envolvendo os fatos, era plenamente possível a revista pessoal e veicular, independentemente de mandado.

Ressalte-se, outrossim, que o inquérito é mero procedimento administrativo-informativo, razão pela qual as investigações realizadas pela autoridade policial não se confundem com instrução criminal, motivo pelo qual eventuais irregularidades por ventura nele ocorridas, não são capazes de ensejar nulidade do processo, o qual, no caso em análise, transcorreu de forma regular e sem vícios

Oportuno, ainda, frisar que "em processo penal, vigoram os princípios de que 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP)" (STJ 5ª Turma, RHC nº 38.424/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 07/03/2005).

No mérito, diante da prova existente verifica-se que a denúncia é procedente.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão da droga e do veículo, bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 21/23, 102/103 e 108/110), provisório e definitivo, os quais confirmam que as substâncias apreendidas são entorpecentes que causam dependência física e psíquica. Incontroversa a prova de autoria.

Na fase administrativa, o réu permaneceu em silêncio. Em Juízo, confessou a traficância, afirmando que aceitou transportar a droga porque estava precisando de dinheiro para pagar dívidas e custear o tratamento de saúde do filho. Já havia sido processado por delito idêntico e, por tal motivo, recebia diversas propostas para transportar entorpecentes.

Inegável o valor da confissão judicial, que somente perderá seu valor se desmentida pelas demais provas, nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no caso em tela.

Fortalecendo a prova de autoria, as testemunhas João Carlos Elias Filho e Rafael da Costa Almeida, policiais civis que tomaram parte nas diligências, sempre que ouvidas, narraram como se deu o encontro da substância tóxica em poder dos réus. Relataram, ainda, que havia informações sobre possível entrega de grande quantidade

de entorpecente no posto de combustível Graal, motivo pelo qual realizaram campanha no local. O veículo conduzido pelo acusado estava estacionado no local de madrugada, com ele em seu interior, o que chamou a atenção. Em dado momento, o motorista de um caminhão se aproximou e ingressou no automóvel do réu. Em seguida, dirigiram-se ao estacionamento privativo de caminhões, o que despertou ainda mais suspeitas. Resolveram segui-los, mas acabaram perdendo o veículo de vista. Depois de algum tempo, avistaram o carro do réu deixando o local sentido Rodovia dos Bandeiras, onde o interceptaram. No porta-malas do veículo foram apreendidas as drogas. O réu confessou a traficância informalmente, dizendo que precisava de dinheiro para custear o tratamento de saúde de um de seus filhos. Não conseguiram identificar o motorista do caminhão. O veículo conduzido pelo réu tinha origem ilícita e parecia adulterado.

Os depoimentos colhidos são coerentes, harmônicos e verossimilhantes, não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, artigo 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

Quando não bastasse, em casos de aplicação da Lei de Drogas, a jurisprudência amplamente majoritária não tem feito restrição ao testemunho de qualquer policial, quando o seu depoimento estiver em harmonia com os demais elementos de prova. Mas não é tudo. Para enfraquecê-lo é imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção. E não haveria motivo de eventual trama dessas testemunhas para incriminar falsamente os acusados, restando demonstrada nos autos a traficância.

Nesse sentido é o entendimento do Pretório Excelso, "A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522-9/AC, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC nº 74.608-0/SP, 1ª Turma, Rel. Ministro Celso de Mello DJU 11/04/97).

E no caso dos autos, os relatos dos policiais dão conta da diligência baseada em informação anterior de entrega de grande quantidade de tóxico, bem como que permaneceram em campanha até que avistaram o encontro do réu com outro indivíduo que não foi identificado. Após diligências, conseguiram interceptar o veículo conduzido pelo acusado, ocasião em que foram encontrados diversos tijolos de cocaína.

Observo que tais declarações, em Juízo, vão de encontro à confissão do acusado. As testemunhas Cláudia, Mariane, Renata e Aline, esta última mulher do acusado, arroladas pela defesa nada esclareceram sobre os fatos, limitando-se a afirmar que o réu era funileiro e tinha um filho portador de uma síndrome rara que necessitava de seus cuidados.

Como se vê, o conjunto probatório amalhado aos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu nos exatos termos da inicial acusatória, posto que evidenciado o intuito de mercancia.

Para tanto, deve ser ressaltado as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas e como se deu a prisão do agente.

Note-se, agora, que as substâncias tóxicas foram apreendidas divididas e acondicionadas em porções, para a venda no atacado, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

É possível, em consequência, o uso de prova indiciária, a qual também está em harmonia com o princípio do livre convencimento do juiz (cf. artigos 239 e 157, ambos do Código de Processo Penal).

Ensina Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, nº 5, pág. 96).

Inviável o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude do estado de necessidade, porquanto a simples alegação de necessidade não basta para configurar a excludente. Além do mais, a prática de condutas ilícitas não é única forma de superar a carência econômica tampouco a situação de pobreza pode servir de salvo-conduto à prática do nocivo tráfico ilícito de entorpecentes.

Ora, o réu tem profissão, trabalhava como funileiro e poderia continuar com seu trabalho lícito, especialmente, diante da triste doença de um de seus filhos. Preferiu voltar ao tráfico.

Nesse teor jurisprudência do extinto Tribunal de Alçada Criminal, “É impossível aceitar-se a tese do estado de necessidade se o réu podia superar esta circunstância, passando a desenvolver trabalho lícito e honesto, pois a discriminante só pode ser reconhecida em face da presença de perigo atual e inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado, sendo certo que a hipossuficiência e as dificuldades financeiras nunca podem justificar a prática de delitos contra o patrimônio, já que se assim fosse, estaria justificada e legitimada a maioria dos furtos e roubos que ocorrem no Brasil, país pobre e subdesenvolvido” (RJTACRIM 37/143).

E mais, o estado de necessidade deve ser cabalmente comprovado sob pena de se criar garantia de impunidade, dissociada do conjunto fático-probatório.

Dessa forma, insubsistente a alegação da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Concluindo, o conjunto probatório é suficiente para dar credibilidade à acusação.

Ante o exposto, afastada a preliminar, julgo PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR o réu MÁRCIO MORAES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Observando os elementos norteadores contidos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser fixada bem acima do patamar mínimo, em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (hum mil) dias-multa, ante a enorme quantidade de tóxico apreendida, além dos maus antecedentes do acusado, condenado por delito idêntico. Note-se que a “Quantidade e qualidade da droga apreendida é circunstância que deve ser sopesada na primeira fase de individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006” (cf. STF, 2ª Turma, RHC 111.440/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-094, 15/05/2012).

Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante da confissão reduz a sanção de 1/6 (um sexto), somando 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Não é caso de reconhecer a existência da atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, como quer a defesa, vez que inviável se aceitar genericamente a condição de vulnerabilidade, pobreza ou uma outra condição social adversa, como circunstância atenuante, sob pena de se gerar uma insegurança no sistema penal pelo equívoco de que o fator econômico-social explica a criminalidade.

Ensina Guilherme de Souza Nucci, “(...) ainda que se possa concluir que o Estado deixa de prestar a devida assistência à sociedade, não é por isso que nasce

qualquer justificativa ou amparo para o cometimento de delitos, implicando um fator de atenuação da pena. Aliás, fosse assim, existiram muitos outros 'cocalpáveis' na rota do criminoso, como os pais que não cuidaram bem do filho ou o colega na escola que humilhou o companheiro de sala, tudo a fundamentar a aplicação da atenuante do art. 66 do Código Penal, vulgarizando-a. Embora os exemplos narrados possam ser considerados como fatores de impulso ao agente para a prática de uma infração penal qualquer, na realidade, em última análise, prevalece a sua própria vontade, não se podendo contemplar tais circunstâncias como suficientemente relevantes para aplicar a atenuante. Há de existir uma causa efetivamente importante, de grande valor, pessoal e específica do agente e não comum a inúmeras pessoas, não delinquentes, como seria a pobreza ou o descaso imposto pelo Estado -, para implicar na redução da pena." (cf. Código Penal Comentado, RT, 13ª edição, pág. 248).

Não é caso de aplicação da causa especial de diminuição, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, considerando a quantidade de droga apreendida e os maus antecedentes do acusado, o que demonstra sua dedicação ao crime.

A sanção privativa de liberdade ora aplicada será cumprida em regime fechado, uma vez que se trata de crime gravíssimo, eis que a real intenção do traficante é amealhar o maior número de vítimas, comprometendo toda a sociedade.

Observe-se, por oportuno que mesmo a fixação da pena-base no mínimo legal cominado a espécie não é fator determinante para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena.

Analisando a última parte do artigo em comento "estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime" tem-se que o regime inicial fechado é o único satisfatório em relação à gravidade objetiva do fato, uma vez que a conduta do acusado colocou em risco, não apenas a saúde do usuário, mas, também, a integridade de toda a sociedade.

O réu não poderá apelar em liberdade, porquanto permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos autos, oficiando-se.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra.

Assim, fica o réu MÁRCIO MORAES DE OLIVEIRA, condenado à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

Oficie-se à autoridade policial conforme requerido pelo Promotor de Justiça, observando-se que deverá ser apurado em autos apartados, comunicando-se diretamente o Ministério Público.

P.I.C.

Jundiaí, 29 de novembro de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito